

1500243-34.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... e recolhendo dinheiro do tráfico no bairro; informou, ainda, que o réu utilizava um veículo. Deparam-se com Daniel dirigindo o veículo, dentro do qual havia, embaixo do tapete, 3 kits de maconha. Daniel confessou a venda dos entorpecentes e informou que em sua residência havia mais drogas e dinheiro oriundo do tráfico. Na residência do réu (a entrada foi autorizada por ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500243-34.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047064/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23099676 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 406/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2047064 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

DANIEL FELIX GOUVEA

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

25/05/2022

Em 25 de maio de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a REBECA UEMATSU TEIXEIRA, MM^a Juíza de Direito Substituta, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu DANIEL FELIX GOUVEA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. João Pedro de Oliveira Masson OAB 94899/RS. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas João Batista de Almeida (GCM), Teresa Pires Garcia e Fernando Neves dos Santos (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19

(Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA, processada pelo procedimento especial previsto na Lei de Drogas, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do DANIEL FELIX GOUVEA, devidamente qualificado nos autos, o qual foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, eis que, no dia no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 16h45, na Rua Antônio Orlando Salmasi, nº 509, Vila Vicente Correa, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 56 porções de crack, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 11 gramas, 14 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 12 gramas e 85 porções de maconha, com peso bruto aproximado de 144 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, utilizando-se de seu veículo, circulava pelo bairro entregando entorpecentes ao demais "vendedores" e guardava o restante, em maior quantidade, em sua residência, visando dificultar eventual apreensão policial. Guardas Civis Municipais estavam em serviço quando receberam denúncia de que um indivíduo de nome Daniel, estaria fazendo a distribuição de drogas para "os moleques", que ficavam localizados nas vielas da linha férrea, e que Daniel estava, naquele momento, transitando pelo bairro, realizando o recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas, a bordo de um veículo VW Parati, cor prata, placas CGI2926. Assim, em buscas pelo bairro, na Rua Antônio Orlando Salmasi, de fato, localizaram o acusado conduzindo o veículo mencionado, sendo deliberada por sua abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder de DANIEL, porém em seu carro localizaram 03 kits de maconha, totalizando 42 porções da droga. Questionado, o réu confessou informalmente a traficância, e afirmou para a guarnição que em sua residência, próxima do local, teria mais entorpecentes armazenados. Assim, deslocaram-se à casa de DANIEL, que franqueou a entrada aos guardas civis, e após revista no imóvel encontraram mais 43 porções de maconha, 56 porções de crack, 14 porções de cocaína do tipo aricanduva, e a quantia de R\$ 1.046,00 em espécie, além de petrechos utilizados para o fracionamento e armazenamento de entorpecentes, quais sejam, uma balança de precisão, uma faca grande que aparentava ter resquícios de maconha, sacolés diversos e um rolo de fita crepe. O réu, embora não notificado pessoalmente, apresentou Defesa Preliminar por meio de Defensor Constituído (fls. 95/101). Assim, por decisão proferida no dia 11 de maio de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 106/109). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos termos da exordial, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas, bem como a quebra da cadeia de custódia. No mérito, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Folha de antecedentes a fls. 24/25, bem como Certidões a fls. 22/23. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, cabe ressaltar que não houve qualquer quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova produzida sobre as drogas apreendidas nos autos. Isso porque a cadeia de custódia é "entendida como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em

vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”, nos exatos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal. Dito de outro modo, consiste no procedimento tendente a garantir a higidez da prova produzida sobre um vestígio do crime, legitimando seu uso, em forma de prova, em desfavor de agente processado criminalmente. No entanto, como o próprio C. STJ julga: “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/2/2022). Como se vê, não foram traçadas balizas normativas para dimensionar as consequências jurídicas da atipicidade procedimental da cadeia de custódia. E, portanto, conforme julga o C. STJ: “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/2/2022). Em síntese, nem toda atipicidade procedimental da cadeia de custódia conduz a imprestabilidade da prova produzida, devendo ser perquirido a intensidade do desrespeito ao modelo típico legal e se houve eventual comprometimento de sua eficácia probatória, em análise conjunta com os demais dados de prova produzidos. Com essa premissa estabelecida, observo que, realmente, há falta de documentação no que tange a “fixação” do vestígio (art. 158, inciso III, do CPP). Entretanto, a despeito de não se revestir de forma documental, a “descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames” (art. 158, inciso III, do CPP) foi realizada por meio de prova oral, em especial dos depoimentos dos Guardas Civis Municipais. Esses agentes públicos, cujo valor probatório de seus depoimentos não se distinguem de qualquer outra testemunha, afirmaram com suficiente precisão o local de apreensão de drogas. Não há, portanto, a despeito da falta de documentação nos autos, provas de comprometimento da cadeia de custódia. Pelo contrário, há provas de foi respeitado, na maior medida possível, o procedimento de cadeia de custódia, pois os guardas civis municipais relataram que, tão logo suspeitaram que as substâncias encontradas no carro do réu e em sua residência eram drogas, adotaram comportamentos tendentes a apreender e coletar o material, descrevendo, de forma mais minuciosa possível, a localização do entorpecente. Logo em seguida, os objetos apreendidos foram entregues à Polícia Civil, que lavrou o competente auto de exibição e apreensão (fls. 113/115), bem como o auto de constatação preliminar (fls. 16/17), descrevendo as drogas de forma minudente e o acondicionamento de forma prevista pela Lei nº 11.343/06. Ao término dessa etapa, com lacre para garantir a inviolabilidade do material apreendido, remeteram ao competente setor de perícias. Nesse setor, o material coletado chegou acondicionado em embalagem plástica incolor e inviolado, pela ausência de rompimento do lacre. Assim, foi produzida a prova pericial questionada através de métodos científicos, seguindo a metodologia apropriada e apresentando a devida conclusão pericial, sendo, tudo isso, documentado em laudo pericial (fls. 70/75). Como se vê, não houve nenhuma

desobediência à cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) capaz de macular a conclusão pericial ou induzir dúvida a respeito do que foi atestado pelos peritos. Dito de outro modo, se houve atipicidade procedimental (não documentação da “fixação” dos vestígios), essa não foi suficiente a comprometer a prova produzida sobre esse elemento coletado. E se não há prejuízo, não há nulidade, conforme preceitua o art. 563 e 566, ambos do CPP, que dispõe, respectivamente e in verbis: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” e “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. A propósito, assim se posiciona o C. STJ: “A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente

mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do *pas de nullité sans grief*.”. (AgRg no RHC 153823/RS, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021). Da mesma forma, afasto a preliminar de nulidade, uma vez que o réu foi preso em situação de flagrante, não havendo irregularidade na conduta dos guardas municipais, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “APELAÇÃO CRIMINAL. Recepção. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da prova, em razão de a abordagem ter sido realizada por guardas municipais, rejeitada. Inexistência de irregularidade. Fundada suspeita. Guarda Municipal que também deve zelar pela segurança pública. Prisão em flagrante formalmente em ordem” (TJSP; Apelação Criminal 1501162-74.2019.8.26.0491; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rancharia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022). Quanto ao vídeo juntado aos autos, trata-se de gravação à distância, em que sequer é possível identificar as pessoas ali presentes. Não comprova, portanto, irregularidade na conduta dos guardas municipais. Assim, afastadas as questões preliminares suscitadas, passo ao exame da matéria meritória. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), pelo auto de constatação preliminar (fls. 16/17), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70/75) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 12), manteve-se em silêncio. Em juízo, disse que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Disse que foi a Tatui para trabalhar e estava na casa da tia dele, havia uma semana. Pegou o carro da tia dele para dar uma volta e, quando voltou, os policiais haviam abordado outra pessoa. Então, soltaram essa pessoa e foram até ele (réu). Algemaram e o levaram para uma casa, onde o portão já estava aberto. Negou que houvesse drogas dentro do carro. Disse que não conhecia os policiais anteriormente. Não apresentou a versão dele dos fatos na delegacia porque estava com medo. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – resta evidente que o acusado negou peremptoriamente a prática do crime. No entanto, não apresentou versão sólida e coerente que lastreasse sua negativa de autoria, tampouco indicou provas que corroborassem sua versão. De outro lado, o Guarda Civil Municipal João Batista de Almeida, em sede policial (fls. 08/09), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia II. Então, foram acionados por um popular, o qual informou a equipe de que um indivíduo de nome Daniel, o qual estaria dirigindo um veículo Parati prata, placas CGI 2926. Segundo o denunciante, essa pessoa estaria fazendo a distribuição de drogas para “os moleques”, os quais se localizam nas vielas da linha férrea. Ainda de acordo com a informação, Daniel estava naquele momento transitando pelo bairro, realizando a recolha do dinheiro. Então, foram até a Rua Antonio Orlando Salmasi, onde localizaram o automóvel do acusado e o abordaram. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o acusado. Porém, ao vistoriarem o carro dele, lograram êxito em localizar 03 kits de maconha, as quais totalizam 42 porções da droga encontrada. Instado, o acusado assumiu a traficância, bem como se apresentou como sendo o gerente daquela localidade e mencionou para a guarnição que em sua residência, a qual é próxima do local da abordagem, teria mais entorpecentes armazenados. Assim, dando continuidade às diligências, após DANIEL ter franqueado a entrada da equipe policial na casa, encontraram mais 43 porções de maconha, 56 porções de pedras de crack, 14 porções de cocaína do tipo aricanduva, uma quantia de R\$ 1046,00, a qual ele afirmou ser proveniente do tráfico ilícito de drogas, além de 01 balança de precisão, 01 faca grande, a qual aparentava ter resquício de maconha, sacolés diversos, um rolo de fita crepe e um videogame playstation 3, o qual DANIEL não soube discorrer sobre a sua origem. Em juízo, disse que estava em patrulhamento, quando um transeunte informou que Daniel estava distribuindo entorpecentes e recolhendo dinheiro do

tráfico no bairro; informou, ainda, que o réu utilizava um veículo. Deparam-se com Daniel dirigindo o veículo, dentro do qual havia, embaixo do tapete, 3 kits de maconha. Daniel confessou a venda dos entorpecentes e informou que em sua residência havia mais drogas e dinheiro oriundo do tráfico. Na residência do réu (a entrada foi autorizada por ele e não houve uso de algemas), foram localizados entorpecentes, além de 1046 reais em dinheiro. Também encontraram uma balança de precisão, uma faca com resquíio de maconha, sacolés, um rolo de fita crepe. Já conhecia o réu antes desse dia, porque havia denúncias anteriores no sentido de que ele era o gerente do tráfico no bairro. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Fernando Neves dos Santos, em sede policial (fls. 10), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento, quando foram informados de que Daniel estava numa Parati prata entregando entorpecentes e recolhendo dinheiro. Lograram êxito em localizar o réu na Parati. Dentro do veículo, havia 3 kits de maconha. O réu assumiu a venda da droga no local e disse que era o "gerente". Informou, ainda, que o restante da droga estava em sua residência. Dentro da casa dele (a entrada foi autorizada), encontraram entorpecentes, uma balança de precisão, uma faca com resquíios de maconha e 1.046 reais. Já conhecia o réu porque se comenta pelo bairro que ele é gerente da biqueira, juntamente com "Dodô". Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, em sede judicial, a testemunha Teresa Pires Garcia afirmou que mora em uma rua um pouco distante do local dos fatos. Viu quando o réu foi abordado. Ele foi conduzido a um imóvel que não pertence a ele. Não se recorda o endereço para onde ele foi levado, nem sabe quem mora naquela casa, apenas sabe que não é a casa do réu. Disse que os policiais o algemaram. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas no carro do acusado e o restante em sua casa; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70/75), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal

contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos (56 porções de crack, 14 porções de cocaína e 85 porções de maconha); 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) a localização, na casa do réu, de diversos instrumentos (balança de precisão e faca), bem como invólucros para acondicionamento (sacólés), para a preparação e fracionamento de drogas; 5) a exata correspondência do réu, inclusive de seu veículo e de seu nome, com o traficante delatado que atuava no local onde ele foi preso; e 6) a informação dos guardas, de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523;

RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Ressalte-se que a versão do acusado não veio acompanhada de outras provas. Não foram arroladas testemunhas que comprovassem que, de fato, o acusado estava em Tatuí há apenas uma ou duas semanas. A única testemunha arrolada pela Defesa, apresentou relatos confusos e pouco convincentes, não sendo suficiente para corroborar a versão do acusado. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 70/75) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, e as específicas, tratadas no art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, considerando a quantidade de drogas de diversas espécies de entorpecentes (56 porções de crack, 14 porções de cocaína e 85 porções de maconha) traficadas pelo acusado. Desse modo fixo sua pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Considerando que o acusado possuía menos de 21 anos à época dos fatos, aplico a atenuante de menoridade relativa, atenuando sua pena até o mínimo legal, isso é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguia de outras causas modificadoras da pena a incidir. Convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que: 1) traficava elevada quantidade de drogas de diversas espécies de entorpecentes (56 porções de crack, 14 porções de cocaína e 85 porções de maconha); 2) possuía apetrechos utilizados para a preparação e o acondicionamento de drogas (balança de precisão e diversos sacolés vazios); e 3) se identificou, aos guardas, como sendo o “gerente” do tráfico realizado no local dos fatos. Como se vê, tais circunstâncias revelam a habitualidade delitiva, denotando reiteração da ação criminosa e que, portanto, o réu em questão se dedicava habitualmente ao exercício de atividade ilícita, a saber, o tráfico de drogas. E tais conclusões não decorreram apenas da quantidade e diversidade de drogas, mas de sua análise conjugada com os demais elementos de provas coligidos nos autos, como acima exposto. E, por isso,

está de acordo com a jurisprudência do C. STJ: "7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa." (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 2º, b, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada. A tão só quantidade de pena aplicada obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu DANIEL FELIX GOUVEA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Defiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que permitiram ao acusado responder a esse feito solto (fls. 32/36). Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado (fls. 152), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 78) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 1.045,00 em dinheiro - fls. 63) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Escorado na mesma fundamentação legal, determino o perdimento do veículo apreendido (VW Parati Atalnta 1.8, de placas CGI 2926 - Itapetininga/SP - fls. 14), em favor da união, apropriado ao Funad, posto que se comprovou que este veículo era empregado pelo réu para o transporte e entrega de drogas. Destaque-se, em se tratando de bem móvel, presume-se que o possuidor do veículo - in casu o réu - é seu proprietário e, portanto, a indicação de outra pessoa no registro do automóvel não obsta a decretação do perdimento deste bem, pois tal discrepância constitui mera irregularidade administrativa. Até mesmo porque, comprovada a utilização do bem para o exercício da narcotraficância, a identificação de seu titular, para fins de perdimento, é irrelevante. Neste sentido: Tráfico de entorpecentes. Condenação. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. Claro envolvimento do réu com a criminalidade. Inaplicabilidade. Decretação de perdimento de veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes. Propriedade do bem irrelevante. Uso para o crime configurado. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00172372320118260047 SP 0017237-23.2011.8.26.0047, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 31/01/2013, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2013) (grifos aditados) Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Aguarde-se eventuais manifestações de interesse na interposição de recurso dentro do prazo legal. Com o trânsito em julgado da

condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA